

1500442-32.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexos finalístico entre as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500442-32.2021.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500442-32.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2289953/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20998311 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5125/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2289953 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 5125/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO AURELIO DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Marcio Aurélio Dias dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, pois, no dia 23 de outubro de 2021, na Rua Santos, nesta cidade e Comarca, ele trazia consigo, para fins de mercancia, cento e dezenove pinos e uma porção compacta de crack, bem como cinco munições de calibre .38, uma chave falsa e uma motocicleta furtada, quando foi surpreendido pela Polícia Militar (fls. 121/124).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 24 de outubro de 2021 (fls. 82/86).

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 177/181).

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022 (fls. 188/189).

O acusado foi citado (fl. 165).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado, que embora tenha negado a comercialização de drogas e munições, afirmou que as

transportava a pedido de terceiros.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP a Defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, que foi indeferido pelo juízo (fls. 210/213).

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva estatal, ao passo que a Defesa sustenta a insuficiência probatória, já que os policiais não presenciaram a comercialização de drogas, e pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da imputação e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.340/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 49/54), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 40/41), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 46/48 e 126/128), pelos laudos de exames de potencialidade lesiva das munições (fls. 107/109) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, os policiais militares Evandro Amaral de Lima e Osmir Class, em Juízo, declararam que na data dos fatos realizavam patrulhamento quando viram um motociclista parar bruscamente em frente a um estabelecimento comercial e nele ingressar sem tirar o capacete, o que lhes gerou desconfiância. Disseram que realizaram a abordagem do acusado e o submeteram à revista pessoal, ocasião em que encontraram, no interior de uma pochete, cinco munições, as drogas e dinheiro. Acrescentaram que o acusado segurava uma chave micha e é conhecido por realizar a comercialização de drogas em sistema de delivery, além do que a motocicleta era originada de furto.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado rechaçou a comercialização de entorpecentes, mas confirmou a posse das drogas e das munições apreendidas, as quais estavam no interior de sua pochete e lhe foram entregues por Rosângela, a qual lhe solicitou que entregasse tais objetos à Karen, nos "predinhos do Santo Antônio", sendo que para prestar tal serviço perceberia um pedaço de crack. Contou ser dependente químico e que havia comprado drogas de Rosângela e Sizenato, os quais foram presos pela Polícia Militar após as informações que prestou quando foi abordado. Confirmou ter furtado a motocicleta que estava sob a sua posse.

À toda evidência, a detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos permite inferir, com clareza, a prática dos crimes pelo acusado.

Ora, apesar de negar a comercialização, o acusado confessa que trazia as drogas consigo a fim de entregá-las à terceira pessoa – conduta que se subsume com perfeição ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06. Nesse ponto, resta rechaçada a tese defensiva de que os policiais não flagraram o agente comercializando as drogas com terceiros, porquanto tal circunstância é irrelevante diante da classificação do tipo penal em comento como misto, ou alternativo, de modo que a prática de qualquer uma de suas condutas nucleares é bastante e suficiente para fins de tipicidade.

Da mesma forma, o mero transporte de munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é conduta tipificada pelo art. 14 da Lei 10.826/03. Vale memorar, a propósito, que a mera apreensão de munições, ainda que de uso permitido e desacompanhadas de dispositivo deflagrador, é suficiente para tipificar o delito em testilha, que é classificada como de mera conduta e perigo abstrato.

Não prospera, por consequência, a alegação defensiva de que o acusado é perseguido pelos policiais militares, eis que ele confessou de maneira circunstanciada a posse das drogas e das munições, bem como firmou a destinação dos objetos: o transporte para entrega a terceiros.

Não há se falar, também, em desclassificação da imputação. A quantidade de drogas

apreendidas (cento e quatorze microtubos de cocaína), as prévias informações possuídas pelos policiais acerca da traficância pelo réu e a confissão deste tornam inequívoca a tipicidade da conduta, que se adéqua ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Destarte, tanto a existência quanto a autoria dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/2003 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório, aplicação do princípio do in dubio pro reo ou mesmo desclassificação. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga não revelam desvalor a justificar o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de modo que, nesta fase, utilizo uma delas (autos n. 0011610-83.2011.8.26.0032), evitando-se, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ). Ausentes provas acerca da conduta social do agente. A personalidade é circunstância neutra ante a falta de amparo probatório. O motivo do crime é próprio à espécie, assim como as suas circunstâncias e consequências. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e do crime do art. 14 da Lei 10.826/03 em 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço e valoro a confissão do acusado, nos estritos termos do art. 65, III, 'd', do CP, e da Súmula 545 do STJ. Lado outro, o acusado é multirreincidente (art. 61, I, c.c 63, ambos do CP). À luz do disposto no art. 67 do CP, da multiplicidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a parcial compensação de tais circunstâncias, com preponderância da agravante. Ademais, a quantidade de condenações justifica a utilização de patamar superior ao ideal de um sexto, motivo pelo qual se acolhe o de um quarto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) Logo, utiliza-se o patamar de um quarto, reduzindo-o pela metade em virtude da parcial compensação decorrente da confissão (patamar efetivo de um oitavo), de modo que a pena intermediária do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 fica estabelecida em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, ao passo que a do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 fica estipulada em 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento.

Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. Desse modo, a pena final do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, ao passo que a do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Os crimes, embora praticados no mesmo espaço temporal, não guardam relação de dependência e se revestem de autonomia. Não há qualquer evidência que as munições – que estavam desacompanhadas de arma de fogo – eram utilizadas para o êxito da traficância. Além disso, os ilícitos foram perpetrados mediante mais de uma ação,

razão pela qual se aplica à hipótese a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento desta Corte Superior, "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexu finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico" (HC n. 181.400/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). 2. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de provas de que o tráfico foi exercido com o emprego de arma, destacando que a arma era para defesa pessoal do agente criminoso e não para a garantia do sucesso das atividades no tráfico, tanto que não sacou a arma ao se deparar com policiais, ou seja, tratando-se de crimes praticados em contextos diversos, não há como revisar essa conclusão, a fim de proceder à desclassificação pleiteada, sem incursão no suporte fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 676.665/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. [...]. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO. [...] Havendo as instâncias ordinárias consignado que a conduta de porte de arma de fogo é autônoma ao delito de tráfico de drogas, correta é a incidência do cúmulo material, não havendo possibilidade de, na via do writ, modificar a conclusão da Corte local para fazer incidir, na espécie, a regra do concurso formal de crimes. Precedentes. - [...] (STJ - HC 410152 / RS 2017/0186935-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Data do Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA).

Destarte, a pena definitiva é de 09 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão e 667 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §§2º, 'b', e 3º, do CP, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tal cenário não resta alterado, por ora, pela aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Ainda em vista da natureza da infração prevista na Lei 11.343/06, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (art. 44, I e II, e 77, I, do CP, e art. 44 da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Marcio Aurélio Dias como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, à reprimenda de 09 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 667 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Lado outro, porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu,

cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu à prisão.

Condene o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, determino o encaminhamento das munições ao Comando do Exército.

O veículo apreendido já foi restituído (fls. 43/44).

A chave micha, embora não tenha relação com o objeto deste feito, está apreendido no bojo dos autos e já foi submetida à perícia, motivo pelo qual autorizo a destruição.

Quanto ao noticiado crime patrimonial, indefiro o pedido de extração de cópias dos autos e remessa ao Ministério Público, eis que tal providência pode ser adotada pela própria Promotoria de Justiça quando intimada desta.

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução, assim como o que mais for cabível.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA